



לפני המפקחת על רישום מקרקעין, חיפה
יעל ליבוביץ

תיק תביעה מס': 46/14

בענין :

1. כהן ניסים
כהן נוגה
2. לובצקי ענת
3. יונה אדם
4. רוטנשטיין שמעון
רוטנשטיין ריקה
5. שטרנברג מרינה
דורוגוי אברהם דוד
6. אפורי (צרפתי) רינה
אפורי אליעזר

כולם ע"י ב"כ עו"ד אסיא סיוון
משדרות המגנים 44, חיפה
טל': 04-8552292, פקס: 04-8552112

הנתבעים

נ ג ד

1. דימיניק דנה
דימיניק שי

2. קורן זמיר
קורן רותי

כולם ע"י ב"כ עו"ד יהודה מלאך
מרח' העצמאות 84, חיפה 30043
טל': 04-8622144, פקס: 04-8622145

הנתבעים

פ ס ק - ד י נ

עיקרה של התביעה היא השאלה כיצד יש לאזן בין זכותם של בעלי דירות בבית משותף להוסיף דירות בבית ולהרחיב דירתם אגב חיזוק המבנה מפני רעידות אדמה, לבין זכותם של בעלי דירות אחרים בבית המשותף שלא יפגעו הנוף, האור והאוויר מהם נהנות דירותיהם.

רקע-

1. הבית המשותף נושא ההליך נמצא ברח' אילנות 17, חיפה, מזוהה כחלקה 12 בגוש 12432 ומורכב משני מבנים בהם סה"כ 8 דירות (להלן: "הבית/הבית המשותף"). במבנה המצוי בחזית החלקה (להלן: "המבנה הקדמי") קיימות 6

דירות, אלו הן דירות התובעים, ובמבנה המצוי בעורף החלקה (להלן: "המבנה האחורי") קיימות 2 דירות, אלו הן דירות הנתבעים.

2. בעליהן של שתי הדירות במבנה האחורי הגישו בקשה להיתר בניה במסגרתו ביקשו להרחיב דירותיהם, להוסיף 2 דירות חדשות: האחת, בקומת המרתף והשניה, דירה בת 2 קומות: קומה נוספת (להלן: "הקומה הנוספת") ועליית גג (להלן: "עליית הגג") על גג המבנה הקיים, וכן לחזק את המבנה מפני רעידות אדמה, וזאת במסגרת תכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה – תמ"א 38 (להלן: "תמ"א/תמ"א 38").

3. ביום 13.6.11 קיבלו הנתבעים היתר בניה המותנה בתנאים; אחד התנאים בהם הותנה ההיתר היה חיוב בקבלת אישור הועדה המחוזית לתכנון ובניה למתן פטור מהתקנת מקומות חניה עבור תוספת שתי היחידות החדשות שתוכננו. התובעים אשר התנגדו למתן היתר הבניה הגישו ערר על החלטת הועדה המקומית ובו עתרו כנגד מתן פטור למקומות חניה וכנגד תוספת הקומה הנוספת וקומת עליית הגג. ביום 17.11.11 החליטה הועדה המחוזית לאשר את הבניה, לרבות את בניית הקומה הנוספת וליתן פטור מהתקנת חניות ליחידות החדשות. כמו כן הורתה הועדה על ביטול קומת עליית הגג.

4. הנתבעים הגישו עתירה מנהלית כנגד החלטת ועדת הערר, בה ביקשו לבטל את החלטת וועדת הערר אשר אסרה עליהם את בניית קומת עליית הגג. בפסק דין שניתן ע"י כב' השופטת וילנר ביום 18.4.12 הוחזר התיק לדיון בפני ועדת הערר תוך שכב' השופטת וילנר הורתה לוועדת הערר לשוב ולבחון את האפשרות לאשר את קומת עליית הגג (להלן: "העתירה הראשונה").

5. ועדת הערר קיימה דיון חוזר בתיק במסגרתו אף יצאה לביקור במקום וביום 24.10.12 ניתנה על ידה החלטה ולפיה אין היא חוזרת בה מקביעתה כי אין לאשר את קומת עליית הגג.

6. על החלטה זו הגישו הנתבעים עתירה מנהלית נוספת. כב' השופטת וילנר ביקרה במקום וביום 7.8.13 ניתן על ידה פסק דין בו נקבע כי החלטת ועדת הערר אשר אינה מתירה לנתבעים לבנות את קומת עליית הגג אינה מאזנת כראוי בין האינטרסים השונים ועל כן דינה להתבטל. לעניין החניה הורתה השופטת לנתבעים להציג פתרונות חניה בסמוך לאתר הבניה לאו דווקא בתוך החלקה (להלן: "העתירה השנייה").

טענות התובעים-

7. ככלל, לצורך הרחבת דירות או תוספת דירות נדרשות הסכמות בעלי הדירות בבית מקרב כלל בעלי הדירות בבית המשותף, קרי, מקרב בעלי הדירות בשני המבנים. הנתבעים נעדרים הסכמות של בעלי הדירות במבנה הקדמי. אמנם בחוק החיזוק קיים חריג לכלל זה בדמותו של סעיף 11 לחוק המקרקעין (חיזוק

בתים משותפים מפני רעידות אדמה), תשס"ח-2008 (להלן: "חוק החיזוק"), ולפיו יראו כל מבנה או אגף כבית משותף, אך חריג זה חל רק בתנאי ש-"**אין בביצוע עבודה במבנה או באגף כדי לפגוע בזכויותיו של בעל דירה במבנה או באגף אחר בבית המורכב**". הבניה נושא ההליך יש בה כדי לפגוע בזכויות בעלי דירות במבנה הקדמי ומשכך סעיף 11 לא חל, והנתבעים צריכים היו לקבל הסכמות מקרב כלל בעלי הדירות בשני המבנים. משלא קיימת בידם הסכמת בעלי הדירות במבנה הקדמי או מי מביניהם ברוב הדרוש דין הבניה לשבט.

8. הבניה המבוקשת תיצור חסימה מוחלטת של נוף, אוויר ואור לדירות המבנה הקדמי בכלל, ולדירות התחתונות שבאותו מבנה בפרט. הנתבעים בעצמם, ועדת הערר וכן השופטת שישבה בדיון בעתירה המנהלית היו תמימי דעים כי בניית הקומה הנוספת יוצרת הסתרה מוחלטת של הנוף הנשקף מהדירות בקומה התחתונה במבנה הקדמי. חילוקי דעות התגלעו רק באשר למידת ההסתרה שתיצור עליית הגג. כפועל יוצא מאישור הקומה הנוספת תגרם לתובעים ירידת ערך משמעותית של דירותיהם.

9. הנתבעים טענו בפני מוסדות התכנון כי קמה להם הזכות לבנות את הקומה הנוספת ואת עליית הגג מכוח תוכניות בנין עיר (תב"ע) אחרות רלבנטיות (ולאו דווקא מכוח תמ"א 38). עם זאת, הוספת דירות שלא מכוח תמ"א 38 טעונה הסכמה של 100% מבעלי הדירות בבית והרחבת דירה טעונה הסכמת של 3/4 מבעלי הדירות שלהם צמודים 2/3 מהרכוש המשותף, ועל בניה שכזו לא חל סעיף 5 לחוק החיזוק הנותן סמכות למפקח לאשרה גם ברוב מופחת.

10. הנתבעים עושים שימוש בזכויות בניה מעבר לחלקם היחסי ברכוש המשותף ובכך הלכה למעשה גורעים מזכויות הבניה של התובעים. אציין כבר עתה כי טענה זו נזנחה בהמשך ההליך.

11. במסגרת הבניה יצומצם המרווח הקיים בין המבנים, מה שיפגע באפשרויות ההרחבה העתידיות של התובעים, אשר באפשרותם להתרחב רק על חשבון שטח זה, זאת להבדיל מהנתבעים שלהם אפשרות להרחיב דירותיהם באופן מדורג לכיוון עורף החלקה. בנסיבות אלו סבורים התובעים כי מן הדין להותיר את המרווח בין המבנים פנוי לשימוש העתידי של התובעים. אמנם לכאורה לבעלי הדירות בשני המבנים זכות דומה להרחבת דירותיהם על חשבון מרווח זה, אך בהינתן שהתובעים מהווים 3/4 מהדירות שלהם צמוד 2/3 מהרכוש המשותף יש לכבד רוב זה ולהותיר בידיהם את הזכות למנוע ממיעוט בעלי דירות להתרחב על חשבון מרווח זה.

12. הבניה המתוכננת "תפקיע" שטח משותף לצורך הסדרת שביל גישה לבניין האחורי.

13. התנגדות התובעים היא לבנייה לגובה וכן לצמצום המרווח בין המבנים, אך הם אינם מתנגדים להרחבת הדירות הקיימות במפלס בו הן מצויות וכן אינם

מתנגדים להרחבת הדירות בעורף החלקה לכיוון הוואדי, ובתנאי שגובה המבנה האחורי לא יעלה על גובהו הנוכחי. עפ"י חוות דעת האדריכל א. ניסן קיימת חלופה תכנונית לתוספת דירות במסגרת תמ"א 38 אשר אינה מהווה הפרעה לנוף לדירות שבמבנה התובעים. חלופה זו מאפשרת את חיזוק המבנה האחורי תוך הרחבתו לכיוון הוואדי. אין הכרח שתוספת הדירות תיעשה דווקא לגובה ויש להעדיף בנייתן במורד החלקה, כלפי מטה. ראיה להיתכנות בנייה שכזו, וכן לכדאיותה הכלכלית, היא העובדה שבשנת 2009 הציגו הנתבעים לתובעים סקיצה רעיונית של הרחבה לכיוון הוואדי. אין להעדיף את החיסכון בעלויות הבניה של הנתבעים הנובעת מהוספת דירות לגובה חלף הוספתם במורד על חשבון הפגיעה הקשה שתיגרם לתובעים.

14. התובעים לא השתהו בהגשת תביעתם. כל עוד לא מוצו ההליכים התכנוניים לא היה מבחינתם טעם בהגשת תביעה, באשר לא ניתן היה לדעת איזו תכנית תקבל את האישור התכנוני הסופי. התובעים טרחו והבהירו בכל שלב ובכל ערכאה כי עם תום השלב התכנוני בכוונתם להגיש הליך משפטי במישור הקנייני. על אף העובדה שהתביעה הוגשה כבר ביום 11.2.14 והומצאה לנתבעים ביום 16.2.14 בחרו הנתבעים לשלם אגרות בניה והיטלים לאחר הגשתה ביום 5.3.14. דהיינו לאחר הגשתה, וחרף העובדה שידעו אודות ההליך המשפטי שנפתח כנגדם. ויוטעם, הרצינול העומד מאחורי טענת השיהוי הוא מניעת מצג של צד להליך לפיו ויתר על זכויותיו והשלים עם המצב הקיים. לטענת התובעים לנוכח ההליכים שנוהלו על ידם – לא כך הדבר. בנסיבות אלו, ככל שהוציאו הנתבעים כספים כלשהם אזי עשו כן על אחריותם בלבד.

טענות הנתבעים-

15. התובעים לא הגישו עתירה על החלטת ועדת הערר מיום 17.11.11 אשר התירה את בניית הקומה הנוספת. בעקבות זאת, במסגרת העתירה המנהלית הראשונה לא נדונה הקומה הנוספת. קומה זו גם לא נדונה בוועדה המחוזית, אליה הוחזר התיק, וממילא לא נדונה בעתירה המנהלית השנייה שהגישו הנתבעים לאחר קבלת החלטת הנוספת של הוועדה המחוזית.

16. משלא הגישו התובעים עתירה כנגד החלטת ועדת הערר מיום 17.11.11, אשר התירה את בניית הקומה הנוספת, ולא נקטו בהליך מינהלי או משפטי אחר על מנת לתקוף אותה, גילו הם, למעשה, דעתם כי אין הם מתנגדים להקמת הקומה הנוספת. משכך החלטת ועדת הערר בעניין זה הפכה לחלוטה, ויש לקבוע כי חל שיהוי בהגשת התביעה לגבי רכיבים אלו של התביעה.

17. פסק הדין שניתן בעתירה המנהלית ביום 7.8.13 חתם שרשרת של הליכים משפטיים ותכנוניים בין הצדדים. על אף העובדה שלאורך כל ההליכים התכנוניים הביעו התובעים דעתם כי אפילו יתקבלו העתירה המנהלית או העררים בכוונתם לפנות מיד לבית המשפט השלום או למפקחת על רישום מקרקעין ולתקוף את ההחלטות במישור הקנייני לא עשו כן גם לא לאחר מתן

פסק הדין בעתירה המנהלית. התביעה דן הוגשה רק ב-2/2014 ובכך למעשה יצרו התובעים אצל הנתבעים את הרושם כי הם משלימים עם שרשרת ההחלטות ופסקי הדין. בעקבות זאת המשיכו הנתבעים לקדם את בקשתם להיתר בניה ואף שילמו למתכננים לצורך התאמת תכניותיהם למבוקש, שילמו אגרות הבקשה להיתר בניה וקיבלו היתר בניה זמני.

18. תובעת מס' 3 באה בנעליו של ה"ה הורוביץ, ממנו רכשה את הדירה. הלה נתן הצהרה ולפיה אינו מתנגד לתוספת עליית הגג מהטעם שהסתרת הנוף שתיגרם מקומת עליית הגג שולית ביותר. תובעים מס' 7 הודיעו לבית המשפט כי קומת עליית הגג לא תגרום להסתרת נוף לדירתם המצויה בקומה העליונה. לאור האמור יש לראותם כמסכימים לבניה.

19. בשנת 2009 הציעו הנתבעים לתובעים לקדם במשותף תוכנית בניה לפי חוק החיזוק. לפי תוכנית זו גובה הבניה במבנה האחורי לא יעלה על גובה מעקות הדירות התחתונות. התובעים סירבו להצעה זו. לאור זאת טענתם כיום כי אינם מתנגדים לבניה לפי חוק החיזוק, ובלבד שלא יעלה גובה הבניה על גובה המבנה האחורי נגועה בחוסר תום לב.

20. התובעים לא טענו בתביעתם כי נדרשת הסכמת בעלי הדירות במבנה הקדמי לשם ביצוע בנייה לפי התב"ע, אלא אך טענו ביחס להיקף השימוש בזכויות מכוח התב"ע, קרי, שהנתבעים עושים שימוש בזכויות בניה העולות על חלקם היחסי. אין לאפשר לתובעים הרחבת חזית זו.

21. היתר הבניה של הנתבעים כולו מכוח התמ"א, ואין לבצע הפרדה מלאכותית של הבנייה המבוצעת, כאילו חלקה מכוח התמ"א ולגביה יחול סעיף 11 לחוק החיזוק, וחלקה מכוח התב"ע ולגביה יחול הרוב הדרוש בסעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין.

22. יש לפרש את התנאי הראשון שבסעיף 11 לחוק החיזוק כמתייחס אך ורק לפגיעה באפשרויות של המבנה השני לבנות אף הוא לפי תמ"א 38. בנסיבות תיק זה ברור ולא הוכחש כי אף המבנה הקדמי יוכל לבנות לפי תמ"א 38. לאור זאת, יש למנות את ההסכמות רק מקרב בעלי הדירות במבנה האחורי שם קיימת להם 100% הסכמה.

23. אינטרס הציבור לחיזוק מבנים על פי התמ"א גובר על אינטרס הפרט לנוף בלתי מוגבל מביתו. משמעות קביעה לפיה כל אימת שיפגע נוף מדירה נתונה, תיסוג התמ"א מפני הנוף, תרוקן את התכנית מתוכן, במיוחד בעיר חיפה לאור המבנה הטופוגרפי שלה. בין פגיעה בנוף לבין מיגון וחיזוק המבנה מפני רעידות אדמה יש להעדיף את ההגנה על קדושת החיים, לא כל שכן בסביבה אורבנית בה לא קיימת זכות קנויה לנוף.

24. גג עליית הגג הוא גג משופע ומשכך אינו מסתיר ואינו חוסם לקומה הראשונה במבנה הקדמי דבר. עפ"י חוות דעת השמאי מטעם הנתבעים הקומה הנוספת תגרום לפגיעה מועטה נמוכה מ-10% משווי הדירות הפרש זניח שיכול להתרחש גם במסגרת מו"מ למכירת דירה.

25. ניתן היה לאשר את הבניה, לרבות תוספת הקומות, גם לפי התב"ע החלה על החלקה, כך שבמועד בו רכשו התובעים דירותיהם בבית ממילא צריכים היו לקחת בחשבון כי הנוף מדירתם עתיד להיחסם בעתיד בהינתן שימושו אחוזי הבניה הקיימים לפי התב"ע.

26. לשם מימון הבנייה נדרשות כל התוספות המבוקשות, והללו עולות בקנה אחד עם מטרת תמ"א 38.

27. הבניה במרווח בין המבנים מינורית ומותירה מרווח נוסף בו יוכלו התובעים להרחיב בעתיד דירותיהם, ככל שיחפצו בכך. בהחלטה הועדה מיום 17.11.11 נקבע כי צמצום המרווח בין המבנים אין בו כדי לפגוע בפרטיות התובעים או לסכל אפשרות בניית ממ"דים בעתיד באותו מרווח לדירות התובעים. לתובעים קיימת אפשרות לבניית ממ"דים גם במרווחים הצדדיים.

28. שינוי שביל הגישה המוביל אל המבנה בעורף החלקה הוא מינורי ואין בו יותר מאשר הסטה קלה של השביל הקיים.

29. לא קיימות חלופות אמיתיות לתוכנית נושא ההליך. בניה בחלקו התחתון של המבנה האחורי, גם אם אפשרית, אינה עומדת בהוראות התמ"א אשר קבעה בסעיף 11.1.2(א) לה כי הקומות לא יחרגו מהקומות שמתחתן. זאת ועוד, בניה לכיוון הוואדי כרוכה בבקשה להקלה שגם אם תאושר תהא כרוכה בהליכים משפטיים ממושכים.

ההליכים בתיק-

30. ביום 20.5.14 וכן ביום 28.9.14 קיימתי ביקורים במקום בנוכחות הצדדים ובאי כוחם, על מנת להתרשם באופן בלתי אמצעי מהנטען. נתוני הביקור במקום יפורטו בהרחבה בפרק הדיון.

31. כחלק מכתבי טענותיהם הגיש כל צד חוות דעת של אדריכל ושל שמאי מקרקעין מטעמו. הצדדים הגיעו להסדר דיוני ולפיו יעידו מטעם הצדדים המומחים בלבד. בדיון שהתקיים ביום 22.5.14 ויתרו התובעים על חקירת השמאי מטעם הנתבעים תוך ששמרו לעצמם את הזכות לטעון בסיכומיהם כנגד חוות הדעת.

32. ביום 22.5.14 וביום 10.9.14 התקיימו דיוני הוכחות בתיק במהלכם העידו מטעם התובעים מר מסראווה סוהיל, שמאי ומר אלי ניסן, אדריכל, ומטעם הנתבעים

העיד מר ירון גרנות, אדריכל. הצדדים הגישו סיכומי טענות בכתב בהם חזרו על עיקרי טענותיהם לעיל, ולא נותר לי אלא להכריע במחלוקות.

מטרת תמ"א 38 וחוק החיזוק-

33. במסגרת הערכות כוללת של מדינת ישראל לרעידות אדמה, התקבלה בשנת 2005 החלטת ממשלה המאשרת את תכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה – תמ"א 38.

34. התכנית מעודדת ביצוע חיזוק בתים משותפים שהיתר להקמתם ניתן לפני 1.1.1980, וזאת מתוך הנחה כי התקן הישראלי לעמידות מבנים ברעידות אדמה (ת"י 413) אשר אושר לראשונה בשנת 1975 החל להיות מיושם רק מס' שנים לאחר המועד הנ"ל.

העידוד מתבטא, בין היתר, בהענקת זכויות בניה ותמריצים נוספים למבנים הטעונים חיזוק דוגמת הטבות מס שונות. היוזמה לביצוע חיזוק מבנה נתונה בידי בעלי הדירות.

35. כנלמד מדברי ההסבר להצעת חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), (הוראת שעה), התשס"ז – 2007, במועד אישור התכנית החליטה הממשלה על הקמת ועדת מנכ"לים אשר תבחן את הצעדים המשלימים הנחוצים ליישום התכנית. בין השאר המליצה הועדה על תיקון חוק המקרקעין.

36. ביום 24.1.2008 פורסם חוק החיזוק ובהמשך תוקן 3 פעמים. במסגרת חוק החיזוק נותר הרוב הדרוש לצורך הוספת דירות כפי שהיה ערב חקיקתו של חוק החיזוק והוא עומד על 100% הסכמה. ואולם, סעיף 5 לחוק החיזוק אפשר לרוב של 2/3 מבעלי הדירות בבית אשר 2/3 מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם לפנות בתביעה למפקח על רישום מקרקעין, אשר ניתנה לו הסמכות לאשר את בניה על אף התנגדות מיעוט בעלי הדירות בבית. התיקונים ביקשו ליצור מנגנונים אשר יקלו על ניצול זכויות בניה וביצוע עבודה ברכוש המשותף הנעשים מכוח תכנית תמ"א 38, תוך יצירת איזון בין מעמדו של הרכוש המשותף וזכויות בעלי הדירות בבית המשותף מצד אחד, לבין הצורך הציבורי החשוב שבחיזוק בתים משותפים לשיפור עמידותם מפני רעידות אדמה מצד שני.

המסגרת הנורמטיבית-

37. סעיף 2 (א) לחוק החיזוק קובע כתנאי סף לבנייה לפי חוק החיזוק קיומו של היתר בניה וזו לשונו:

”ניתן היתר בנייה לביצוע עבודה ברכוש המשותף, עפ”י תוכנית החיזוק... יחולו לעניין עבודה ברכוש המשותף הוראות חוק זה”.

38. ביום 10/1/2011 התקבל בכנסת תיקון חוק החיזוק המרחיב את הגדרת ”היתר בנייה” ככוללת גם בקשה להיתר בתנאים. התיקון לחוק הגדיר בסעיף 1 לו מהי ”החלטה לאשר בקשה להיתר בתנאים” כדלהלן:

”החלטה בדבר אישור בקשה להיתר בתנאים, שהתקבלה במוסד תכנון, לאחר שהתקיימו כל אלה:

1. מוסד התכנון מצא כי הבקשה תואמת לתכנית החיזוק וכן לתכניות תקפות אחרות ולתכניות מופקדות, ולתנאים לפי סעיף 78 לחוק התכנון והבנייה התשכ”ה-1965 (להלן: ”חוק התכנון והבנייה”) ככל שנקבעו;
2. מוסד התכנון מצא כי הבנייה המבוקשת משתלבת במערכות התשתית הקיימות והמתוכננות בסביבתה;
3. הוגשו התנגדויות לבקשה להיתר לפי הוראות חוק התכנון והבנייה – מוסד התכנון החליט בהן;

39. באשר לעבודות חיזוק המשלבות הוספת דירות לבית המשותף קובע סעיף 5 לחוק החיזוק לאמור:

”(א) ביצוע עבודה ברכוש המשותף שמטרתה בניית דירה חדשה אחת או יותר, טעון החלטה מראש של כל בעלי הדירות, כאמור בחוק המקרקעין; ואולם רשאי המפקח, אף אם לא התקבלה על כך החלטה מראש של כל בעלי הדירות בבית המשותף, לאשר את ביצוע העבודה, על פי תביעה של בעלי הדירות שבמועד הגשת התביעה היו בבעלותם שני שלישים מהדירות בבית המשותף ושני שלישים מהרכוש המשותף היו צמודים לדירותיהם, ובלבד שנתן לכל בעל דירה בבית המשותף הזדמנות לטעון את טענותיו. (הדגשה שלי י.ל.).

(ב) אישר המפקח ביצוע עבודה ברכוש המשותף שמטרתה בניית דירה חדשה כאמור בסעיף קטן (א), רשאי הוא להתנות בתנאים וכן ליתן הוראות לעניין סדרי הרישום בלשכת רישום המקרקעין; כן רשאי המפקח, אם ראה שבנסיבות העניין קיימת הצדקה לעשות כן, למנות אדם שהוא עורך דין או רואה חשבון, ושאינו בעל דירה בבית המשותף שלגביו אושר ביצוע העבודה כאמור, אשר יהיה מוסמך, בהתאם להוראות המפקח, להתקשר בשם כל בעלי הדירות בבית המשותף לשם בניית הדירה החדשה ולהעברת זכויות בה לאחר מכן.”

40. סעיף 11 לחוק החיזוק קובע כי בבית המורכב ממספר מבנים או אגפים ובהתקיים התנאים האמורים בס"ק 1-2 לו יראו כל מבנה או אגף כבית משותף נפרד, וזו לשונו:

"מבנה או אגף בבית מורכב כמשמעותו בסעיף 59 לחוק המקרקעין, יראו אותו לענין חוק זה כבית משותף, ובלבד שהתקיימו שניים אלה:

- (1) אין בביצוע העבודה במבנה או באגף כדי לפגוע בזכויותיו של בעל דירה במבנה או באגף אחר בבית המורכב;
- (2) ניתן לבצע חיזוק מפני רעידות אדמה של המבנה או האגף, בלי לבצע חיזוק כאמור של מבנה או אגף אחר בבית המורכב."

41. סעיף 59 לחוק המקרקעין מורנו מהו בית מורכב וכך קובע הסעיף:

"(א) מקום שבית משותף מורכב ממבנים אחדים או מאגפים אחדים אשר לכל אחד מהם כניסה נפרדת או מיתקנים נפרדים (להלן - בית מורכב) ובעלי הדירות קבעו בתקנון כי הרכוש המשותף, כולו או חלק ממנו, שבתחומי כל מבנה או אגף יהיה צמוד לדירות שבאותו מבנה או אגף, או שהחזקתו וניהולו יהיו נפרדים, תחול חובת ההשתתפות בהוצאות ההחזקה והניהול של הרכוש המשותף כאמור, על בעלי הדירות שבאותו מבנה או אגף בלבד; בעלי הדירות רשאים לקבוע בתקנון שיקיימו אסיפה כללית ונציגות נפרדת לגבי אותו מבנה או אגף..."

דיון והכרעה-

שיהוי

42. אקדים ואציין כבר עתה כי מצאתי לדחות את טענת השיהוי שהעלו הנתבעים.

43. הנתבעים טענו כי כבר ביום 30.11.11 ניתנה החלטת הוועדה המקומית המאשרת את הבקשה להיתר בתנאים. באותה בקשה אושרו, בין היתר, בניית הקומה הנוספת, קומת עליית הגג והבנייה במרווח שבין המבנים. מאותו המועד המשיכו הצדדים להליך להתדיין בוועדות הערר ובעתירות מנהליות אך ורק לגבי החניות וקומת עליית הגג. ההליכים התכנוניים לגבי הקומה הנוספת ולגבי הבניה במרווח בין המבנים הסתיימו כבר בשנת 2011 והפכו חלוטים. לגישתם בכך הביעו, למעשה, התובעים הסכמתם להקמת הקומה הנוספת ולבנייה במרווח שבין המבנים, והגשת התביעה בעניינים אלו כעת עולה כדי שיהוי.

44. אין בידי לקבל טענה זו. היעלה על הדעת כי בשלב בו עדיין מתקיימים הליכים התכנוניים בעניין עליית הגג וכו' יידרשו התובעים להגיש תביעה משפטית במישור הקנייני כנגד הקומה הנוספת שאינה עוד לדיון במישור התכנוני? תוצאה

זו אינה מתקבלת על הדעת. ברי כי כל עוד הבקשה להיתר בנייה או רכיבים שלה נדונים בפני מוסדות התכנון או מתנהלת לגביה עתירה מנהלית על בעלי הדירות בבית להמתין לסיומם של כל ההליכים התכנוניים כולם טרם שיגישו תביעתם בפני המפקח על רישום מקרקעין.

45. אין בידי להלום כי יש לתקוף כל רכיב בניה בשלב בו הוא הופך חלוט מבחינה תכנונית. יש לראות את מכלול הבקשה להיתר בנייה כעומדת לתקיפה במישור הקנייני מקום שהסתיימו כל הליכי התכנון כולם לגביה. ודוק- אם תתקבל עמדתם של הנתבעים ימצא כי בעל דירה המתנגד לתכנית בניה אשר טרם הסתיימו לגביה כל ההליכים התכנוניים יצטרך להגיש תביעות משפטיות שונות ונפרדות במישור הקנייני כנגד כל רכיב בניה אשר אינו עומד עוד לדיון במישור התכנוני, וטרם שהסתיימו כל ההליכים התכנוניים הרלוונטיים לאותה תוכנית בניה.

46. זאת ועוד, התובעים הבהירו שוב ושוב כי הם מתנגדים לבניה במרווח שבין המבנים וכן לבניה לגובה, וכי בהינתן שהבניה תאושר יגישו תביעה במישור הקנייני. ראו סעיף 26 לכתב ההגנה, וראו נספח מס' 7 לאסופת המוצגים שהגישו הנתבעים. לאור זאת, אין לייחס להם השלמה, הסכמה או ויתור על זכותם זו להגיש תביעה במישור הקנייני. ברי כי בעל דירה המתנגד לבניה ואף ממשיך ומביע מחאתו רשאי להמתין עד תום ההליכים התכנוניים כולם, ורק אז יגיש תביעה משפטית אחת במישור הקנייני כנגד הבניה הסופית אשר אושרה כפי שמורה החוק.

47. זאת ועוד, מוצאת אני גם לקבל את הסברם של התובעים לשאלה מדוע לא הגישו עתירה מנהלית כנגד החלטת ועדת הערר אשר התירה את בניית הקומה הנוספת, כפי שעלה בתגובתם לעתירה המנהלית. התובעים ציינו בתגובתם זו כי, הגם שהתנגדו לבניית הקומה הנוספת אשר פוגעת בהם מאד, הסכימו להצעת וועדת הערר לאפשר את בניית הקומה הנוספת, ובתנאי שתבוטל עליית הגג, בבחינת פשרה בין הצדדים. מכל מקום מרגע שאושרה עליית הגג במישור התכנוני לא ראו התובעים עצמם מחויבים עוד להסכמתם זו.

48. לאור האמור אני דוחה את הטענה לשיהוי.

האם העבודות נשוא ההיתר חורגת מתמ"א 38 ומתחולתו של סעיף 5 (א) לחוק החיזוק?

49. התובעים טענו כי הבקשה להיתר חורגת ממסגרת תמ"א 38, ועושה שימוש גם בזכויות בניה מכוח התב"ע. משכך, לטענתם, אין להחיל על כולה את הרוב הקבוע בסעיף 5 (א) לחוק החיזוק, ועל חלק הבנייה הנעשה מכוחה של התב"ע יש להחיל את סעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין הדורש קבלת רוב של $\frac{3}{4}$ של בעלי הדירות אשר צמודים להם $\frac{2}{3}$ מהרכוש המשותף. רוב שאינו עומד לנתבעים.

50. איני מקבלת עמדתם זו של התובעים ולשם כך אפנה לנוסחו של סעיף 2 לחוק החיזוק המורה כדלקמן:

"(א) ניתן היתר בנייה לביצוע עבודה ברכוש משותף, על פי תוכנית החיזוק, ונדרשת לפי פרק ו' לחוק המקרקעין הסכמה או החלטה של בעלי הדירות בבית המשותף לצורך ביצוע אותה עבודה (בחוק זה – עבודה ברכוש המשותף), יחולו לעניין העבודה ברכוש המשותף הוראות חוק זה. (ב) הוראות לפי חוק המקרקעין ימשיכו לחול על עבודה ברכוש המשותף, ככל שאינן סותרות את ההוראות לפי חוק זה".

"היתר בניה" מוגדר בסעיף 1 לחוק החיזוק כדלקמן: "היתר לפי חוק התכנון והבנייה או החלטה לאשר בקשה להיתר בתנאים".

"החלטה לאשר בקשה להיתר בתנאים" מוגדרת בסעיף 1 לחוק החיזוק כדלקמן:

"החלטה בדבר אישור בקשה להיתר בתנאים, שהתקבלה במוסד תכנון, לאחר שהתקיימו כל אלה: 1. מוסד התכנון מצא כי הבקשה תואמת לתכנית החיזוק וכן לתכניות תקפות אחרות ולתכניות מופקדות, ולתנאים לפי סעיף 78 לחוק התכנון והבנייה התשכ"ה - 1965 (להלן: "חוק התכנון והבנייה") ככל שנקבעו; 2. מוסד התכנון מצא כי הבנייה המבוקשת משתלבת במערכות התשתית הקיימות והמתוכננות בסביבתה; 3. הוגשו התנגדויות לבקשה להיתר לפי הוראות חוק התכנון והבנייה - מוסד התכנון החליט בהן; (הדגשה שלי י.ל.)

"תכנית החיזוק" מוגדרת בסעיף 1 לחוק החיזוק כדלקמן: "תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה (תמ"א 38), כפי שתהיה בתוקף מעת לעת".

ביום 21.5.14 נתנה הוועדה המקומית אישור, אשר הוגש וסומן מס' 1 באסופת מוצגי הנתבעים, בו מאשרת הוועדה כי כל התנאים אותם קבעה הוועדה לצורך קבלת היתר בנייה, מולאו, לרבות התנאים המצוינים בסעיף 1 לחוק החיזוק, ובכלל זה ההוראה הקובעת כי "נמצא כי הבקשה תואמת לתכנית החיזוק תמ"א 38 וכן לתכניות התקפות החלות על המקום".

יוצא אפוא, כי על מנת להיכנס בגדרו של חוק החיזוק, "היתר בנייה" או "החלטה לאשר בקשה להיתר בתנאים", כהגדרתם בחוק החיזוק, אינם צריכים להיות תואמים לתוכנית החיזוק בלבד, ויכול שיהיו תואמים לתכניות תקפות אחרות.

משהתקבל, אפוא, אישור הוועדה המקומית לקיומם של התנאים הנ"ל (שלא נסתרו על ידי התובעים), הרי שאנו נכנסים בגדרו של חוק החיזוק, וכל הסכמה או החלטה של בעלי הדירות בבית המשותף לצורך ביצוע העבודה ברכוש

המשותף בהתאם להיתר הבנייה, תיבחן בהתאם להוראות חוק החיזוק, כאמור בסעיף 2 לחוק.

51. היות ומצאתי להחיל את החוק החיזוק על כל התוכנית נושא הליך זה, והיות והבית המשותף נושא ההליך מורכב משני מבנים, נדרש שאבחן את הוראות סעיף 11 לחוק המקרקעין האם מתקיימות הן לגבי הבית נושא ההליך, באופן שניתן יהיה לראות כל מבנה כבית משותף העומד בפני עצמו, ולבחון רק מקרב בעלי הדירות שבו את היקף ההסכמות לבניה.

החלת התנאים בסעיף 11 לחוק החיזוק-

52. מורנו סעיף 11 כי הסעיף יחול על מבנה או אגף בבית מורכב כמשמעותו בסעיף 59 לחוק המקרקעין ובהצטבר שני התנאים אשר פורטו לעיל.

53. אבחן תחילה את התנאי השני דווקא הקובע כי: **"ניתן לבצע חיזוק מפני רעידות אדמה של מבנה או אגף, בלי לבצע חיזוק כאמור של מבנה או אגף אחר בבית המורכב"**. התובעים לא הכחישו את טענת הנתבעים כי ניתן לבצע חיזוק לכל מבנה בנפרד. טענתם היחידה בעניין זה הייתה שהנתבעים מבקשים לצמצם את המרווח הקיים בין המבנים, והדבר עשוי לסכל אפשרות של בניית ממ"דים לדירותיהם בעתיד כחלק מחיזוק המבנה מפני רעידות אדמה. אל סוגיה זו התייחסה וועדת הערר בהחלטתה מיום 17.11.11 וכך קבעה הועדה: **"ככל שהדבר נוגע לעניין ההתקרבות בין המבנים, לא מצאנו כי ההתקרבות, אשר עומדת על 6.15 מ' מקצה המדרגות המוצעות, ול-7.28 מ' מהאגף בו אין מדרגות גורם לפגיעה מהותית בעותרים...יש לציין כי אם בעתיד יבקשו העוררים לבצע בניית ממ"דים, הדבר יתאפשר גם לכיוון בניין המשיבים, שכן הוספת ממ"דים מתגברת על קביעות בעניין קווי הבניין בתכנית..."**.

54. לאור האמור ומשדחתה הוועדה את טענתם זו של התובעים מוצאת אני לקבוע כי מתקיים התנאי השני ולפיו ייתכן חיזוקו של המבנה הקדמי בנפרד מהמבנה האחורי.

55. כעת אעבור לתנאי הראשון הקובע כי: **"אין בביצוע העבודה במבנה או באגף כדי לפגוע בזכויותיו של בעל דירה במבנה או באגף אחר בבית המורכב"**. הנתבעים הפנו לדברי ההסבר של הצעת חוק החיזוק וביקשו לפרש "פגיעה בזכויות" לפי סעיף זה ככזו הפוגעת באפשרויות החיזוק מכוח תמ"א 38. ראו סעיף 29 לסיכומים.

56. על פי הפסיקה חובה שפרשנות חוק תעלה בקנה אחד עם תכליתו כמו גם עם המדיניות השיפוטית הראויה והרצויה. ראה בסוגיה זו למשל בג"ץ 2599/00 תק-על 2002(3), 217, וכן בבג"ץ 4562/92 **זנדברג נ' רשות השידור**, פ"ד נ(2), 793, 803 שם נקבע כי:

"... אכן, הפירוש ללשון הטקסט יכול שיהא מרחיב ויכול שיהא מצמצם, יכול שיהא רגיל ויכול שיהא חריג, אך הוא צריך תמיד למצוא נקודת אחיזה ארכימדית בלשון החוק... בצד הלשון עומדת התכלית. אלה הם המטרות, היעדים, האינטרסים והערכים אשר הנורמה נועדה להגשים. לכל נורמה תכלית – ולרוב מספר תכליות – שאותן היא נועדה להגשים. נורמה ללא תכלית היא דבר הבל. תכלית של נורמה היא עניין נורמאטיבי. היא נלמדת מלשון הנורמה ומההיסטוריה שלה, מסוג העניין המוסדר ומטיפוס ההסדר. על תכלית הנורמה למד הפרשן מערכי היסוד של השיטה, ובהם הרצון והצורך להגשים ערכי צדק, מוסר וזכויות אדם. מעמדה של הנורמה, יחסה לנורמות שמעליה ומתחתיה והשתלבותה בסביבתה הנורמאטיבית מסייעים בגיבוש תכלית הנורמה, שהרי "דיבור שבחיקוק הוא יצור החי בסביבתו" (השופט זוסמן בבג"צ 58/68 שליט בשמו ובשם ילדיו נ' שר הפנים ואח', בעמ' 513)... צורכי החברה ודרישות המציאות משפיעים על תכליתה של הנורמה. ממקורות אלה כולם למד הפרשן על התכלית המונחת ביסוד הנורמה".

57. אנו מצווים אפוא לפרש את החוק לאור מטרותיו ולצקת בו תוכן המקיים את המטרות הללו. מקום שאפשרית יותר מפרשנות אחת לחוק, שומה עלינו לאמץ את זו המקיימת אותו ועולה בקנה אחד עם יעדיו, ולא את זו המסכלת אותו או מרוקנת אותו מתוכן.

58. יישום כללי פרשנות אלו על תנאי סעיף 11 לחוק החיזוק אינה מאפשרת קבלת הפרשנות המוצעת ע"י הנתבעים, שהרי אם תתקבל פרשנותם זו יימצא שני התנאים בסעיף חד הם, ושניהם באים למעט אפשרות של בניה וחיזוק באגף/מבנה בנפרד מהאגף/המבנה האחר, מקום בו הפרדת הבניה עשויה לסכל אפשרות של חיזוק עתידי של האגף/המבנה האחר.

לדעתי נכון לפרש את הדברים שנאמרו בדברי ההסבר של הצעת החוק כמתייחסים לתנאי השני בלבד, ואין בהם כדי לבטל את התנאי הראשון אשר לשונו הברורה והחד משמעית קובעת כי יראו כל מבנה/אגף בבית משותף כעומד בפני עצמו ובתנאי שלא יהיה בעבודה כדי לפגוע בזכויות של בעל דירה במבנה או באגף האחר. הרציונל לפרשנות זו הוא העובדה שאמנם המחוקק ביקש להפריד בין המבנים ולראות כל אגף/מבנה כישות עצמאית נפרדת אשר ההסכמות לפי סעיפים 3-5 לחוק החיזוק תיבחנה רק מתוכו, וזאת לשם פישוט וייעול הליכי הבניה לפי חוק החיזוק, אך צמצום מרחיק לכת זה ראוי שיתקיים רק מקום בו לא יהיה באותה הפרדה כדי לשלול מהמבנים האחרים אפשרות לביצוע חיזוקים אף הם, ולא יהיה בבניה כדי לפגוע, במובן הפשוט, בזכויות בעלי דירות במבנה האחר.

האם יש בבניה נושא ההליך כדי לפגוע בזכויותיו של בעל דירה במבנה או באגף אחר?

צמצום המרווח ושינוי תוואי השביל-

59. התובעים טענו לפגיעה בזכויותיהם בשל הבנייה במרווח שבין המבנים, שינוי תוואי שביל הגישה הקיים המוביל למבנה האחורי ובניית הקומה הנוספת ועליית הגג.

60. אקדים ואציין כי לא מצאתי ממש בטענות לפגיעה בגין בנייה במרווח בין המבנים מהטעמים שפורטו לעיל, ולא הוכחה לי פגיעה בתובעים בשל שינוי כלשהו שיידרש בתוואי שביל הגישה. ככל שקיימת פגיעה כלשהי בגין רכיבי בניה אלו הרי שהיא זניחה ומתבטלת אל מול הצורך לאפשר חיזוקן של דירות הנתבעים.

בניית הקומה הנוספת-

61. באשר למידת ההסתרה שתיווצר כתוצאה מבניית עליית הגג מוצאת אני להצטרף לדבריה המלומדים של כב' השופטת וילנר באשר לתכלית תמ"א 38 אשר תוארה בפירוט רב בפסק דינה, וכן למסקנתה המפורטת בסעיף 38 לפסק דינה כדלהלן: **"בבואי לאזן בין האינטרסים המנוגדים, הפגיעה הקלה בנוף שתיגרם למש' רוטשטיין (ולה בלבד) כתוצאה מבניית עליית הגג, אל מול האינטרס הציבורי בחיזוק המבנה, דעתי היא כי ידו של האינטרס הציבורי על העליונה"**. (הדגשה שלי י.ל.)

62. אך זאת יש לזכור, נקודת המוצא שעמדה בבסיסו של הדיון שהתקיים בפני כב' השופטת וילנר, וכפועל יוצא בפסק דינה, היא שהערר וכן העתירה המנהלית אשר נדונה בפנייה עניינן היה רק עליית הגג. הקומה הנוספת לא נדונה ולא הוכרעה בדיון שהתקיים בעתירה זו, ולאור זאת קבעה כב' השופטת וילנר בפסק דינה: **"אין ספק כי נוף זה יוסתר ממילא על ידי בניית הקומה הנוספת שאושרה על ידי ועדת הערר ואינה עוד לדיון. על כן, ברי כי בניית עליית הגג לא תשפיע על מידת הסתר הנוף הנשקף מהדירות המצויות בקומה זו"**. (הדגשה שלי י.ל.)

63. ויוטעם, אין בפסק דינה כדי קביעה כי הבניה כולה או למצער הקומה הנוספת לא תגרום לפגיעה בתובעים, מהטעם שהעתירה המנהלית אשר הובאה לפתחה לא נדרשה לבחינת מידת ההפרעה שתיגרם כתוצאה מבניית הקומה הנוספת, אלא עניינה היה אך ורק קומת עליית הגג. לאור זאת ממצאיה מתייחסים אך ורק למידת הפגיעה שגורמת עליית הגג אל מול הצורך בחיזוק המבנה האחורי מפני רעידות אדמה.

64. משכך, והיות ובהליך הקנייני המתנהל לפניי נדונה הבניה כולה ולא רק עליית הגג נדרשת אני לבחון את מידת הפגיעה אשר תגרם לתובעים מהבנייה בכללותה.

65. על מנת להתרשם מהפגיעה שעלולה להיגרם לתובעים קיימתי שני ביקורים במקום. בעניין זה חשוב לעיין בתיאור פירוט הביקור במקום שלהלן תוך עיון בנספחים 11 ו-13 לנספח 2 ממוצגי הנתבעים:

(א) חזיתה של החלקה פונה לרח' אילנות בחיפה ועורפה פונה לכיוון הוואדי. בחזית החלקה ניצב מבנה בן 6 דירות: שתיים בכל קומה, מאחוריו ניצב מבנה נוסף בן שתי דירות.

(ב) החלקה בנויה בשיפוע חד לכיוון הוואדי באופן שגג המבנה האחורי (בו מצויות דירות הנתבעים) מקביל או נמוך מרצפת הדירות התחתונות ביותר במבנה הקדמי (בו מצויות דירות התובעים). בצידה המערבי של החלקה עובר שביל גישה המוביל מהרחוב אל המבנה האחורי. לצורך הגעה למבנה האחורי נדרש לרדת מדרגות רבות, וזאת בשל השיפוע החד של הקרקע.

(ג) החלקה, ובדומה לה גם החלקות הסמוכות לה, ממשיכה מדרום למבנה האחורי מטרים רבים לכיוון הוואדי בהם נטוע חורש טבעי על גבי קרקע בשיפוע חד מאד.

(ד) ניכר כי המרווח הקיים כיום בין המבנים קטן מאד. ואולם, היות והמבנה האחורי כולו נמוך מהמבנה הקדמי על אף המרווח הקטן לא קיימת כיום קירבה בין דירות המבנה הקדמי לדירות המבנה האחורי בהיותן בנויות במפלסים שונים.

(ה) מסלון דירות המבנה הקדמי נשקף נוף ברדיוס של כ- 180 מעלות למרחק בלתי מוגבל. המדובר בנוף יפהפה שופע אור וזרימת אוויר חופשית.

(ו) מסלון הדירות התחתונות בקומת הקרקע של המבנה הקדמי במבט כלפי מטה ניתן לראות את גג המבנה האחורי אך במבט פנוראמי ישר ניתן לראות נוף פתוח. לימין החלון ניתן לראות זוויתית את הים התיכון. ממול הדירה נגלית הצלע הנגדית של הוואדי, ומשמאל לחלון מצוי המשך הוואדי ובתי המגורים. קרוב לחלון הסלון מתנשאים ענפיו של עץ ותיק המתנשא לגובה רב אשר ענפיו מסתירים את מקצת הנוף. לכך אוסיף כי התרשמתי בביקור כי ככל שתבנה הקומה הנוספת במבנה האחורי אזי ייחסם כל הנוף הנשקף מדירות אלו. קירות תוספת הבנייה ייבנו במרחק של כ-6 מטרים מחלונות הסלון ויהיו מקבילים לקירות אלו לכל גובהן (מהרצפה ועד תקרת הדירות התחתונות) וכמעט לכל רוחב דירות אלו. כמעין חומה המוקמת מול חלונות אלו וזאת בסמיכות רבה מאד.

(ז) מסלון הדירות בקומה הראשונה של המבנה הקדמי ניתן לראות, מעבר לעץ, זוויתית את הים התיכון, ממול את הצלע הנגדית של הוואדי, ומשמאל את המשך הוואדי ובתי המגורים. בדומה להתרשמותה של כב' השופטת וילנר בפסק דינה מיום 7.8.13 גם אני התרשמתי כי אל מול מפתחי סלון דירות אלו יתנשאו עליות הגג המשופעות של הבניה המתוכננת, באופן שרום עליית הגג יהיה פחות או

יותר מקביל לקיר המפריד בין דירות הקומה הראשונה ויגיע בערך לגובה מעקה מרפסות הסלון. באופן זה הנוף הנשקף מדירות אלו יפגע חלקית.

(ח) לא מצאתי טעם בבחינת מידת הפגיעה שתיגרם לדירות מעל דירות הקומה הראשונה מהטעם שהצדדים הסכימו כי דירות אלו מצויות מעל גובה רום עליית הגג באופן שלא יושפעו מהבניה לגובה.

66. תחושתי בעקבות הביקורים במקום היא שמילים לא יהא בהן די כדי לתאר את גודל הפגיעה שתיגרם לתובעים כפי שניתן להתרשם בביקור במקום, ועל כך נאמר "אין טוב כמראה עיניים". התרשמתי כי הקומה הנוספת תחסום כליל את הנוף הנשקף מסלון דירות קומת הקרקע ואת האוויר והאור המגיעים לדירות אלו. במרחק קטן ביותר מחלונות סלון הדירות יבנה קיר המקביל למפתחים אלו ואשר מכסה אותם כליל מרצפה לתקרה ומקיר לקיר.

67. הנתבעים בסיכומיהם וכן כב' השופטת וילנר בפסק דינה הפנו לפסקי דין רבים הקובעים כי אין אדם יכול לצפות שלא תהיה התפתחות מתמדת בשכונה המגורים בו הוא חי וכי יובטח לו לנצח הנוף הבלתי מוגבל הנשקף מדירתו. גם אני סבורה כי, ככלל, הזכות לנוף אינה זכות מוחלטת אלא יחסית וכי זכות זו יכול ותיסוג מפני תהליכי התפתחות טבעית של אזור עירוני. עם זאת נקודת האיזון משתנה ממקרה למקרה.

68. הפגיעה שתוסב לדירות התחתונות במבנה הקדמי אינה מידתית שכן היא מהווה חסימה מוחלטת של הנוף, האוויר והאור הנשקף מסלון דירות אלו כיום. פגיעה זו אינה דומה לחסימה חלקית או זוויתית של נוף, אוויר ואור אשר אפשר שתאושר במסגרת האיזונים הנדרשים, וגם אינה לחסימת נוף הנשקף מחלון חדר שינה שבדירה. כאן מדובר בחסימת נוף מוחלטת של סלון הדירה באמצעות קיר שיבנה בסמיכות רבה לפתח.

69. בעוד שמצטרפת אני לדעתה של כב' השופטת וילנר לעניין עליית הגג כי אכן נגרמת פגיעה כלשהי בבעלי דירות הקומה הראשונה אך זו נסוגה מפני האינטרס הציבורי בחיזוק המבנה האחורי, הרי שהתרשמותי לגבי הקומה הנוספת היא שבאיזון האינטרסים של חיזוק המבנה האחורי אל מול הפגיעה בבעלי הדירות בקומת הקרקע במבנה הקדמי, ראוי להעדיף את האינטרסים של התובעים.

70. לטעמי, בנתונים הייחודיים לבית זה לרבות המרווח הקטן הקיים בין המבנים, כל בניית קומה מלאה או כמעט מלאה על גג המבנה האחורי, תגרום להסתרה מוחלטת, כמעין "בלוק" החוסם את כל מפתחי סלון דירות קומת הקרקע, ועל כן תגרום לפגיעה מהותית.

71. לצורך הוכחת הפגיעה בתובעים והיקפה או היעדר פגיעה הביאו הצדדים חוות דעת של שמאים מטעמים. התובעים על מנת לתמוך בטענתם שתיגרם לדירותיהם פגיעה משמעותית ביותר, והנתבעים על מנת להוכיח כי תיגרם לדירות התובעים

פגיעה זניחה אשר יש להתעלם ממנה אל מול הצורך בחיזוק המבנה האחורי. נוכח מסקנתי לעיל לא מצאתי להעדיף חו"ד שמאית של מי מהצדדים על פני התרשמותי דלעיל.

72. חיזוק ועיגון נוסף לדעתי זו מצאתי גם בממצאי וועדת הערר, בפסק דינה של כב' השופטת וילנר ואף בעמדות הצדדים, אשר יפורטו להלן.

עמדת הנתבעים בסוגיה-

73. הנתבעים בעצמם הודו כי הנוף הנשקף מדירות קומת הקרקע במבנה הקדמי ייחסם לחלוטין. כבר בעתירה המנהלית שהגישו הנתבעים קובעים הם בסעיף 3.22 כדלהלן: **"ביצוע הבניה במתכונת המותרת בהחלטת ועדת הערר תוך הוספת קומה אחת, (ללא עלית גג), כבר היא כשלעצמה אינה מותירה כל השקף נוף לקומת הקרקע."** (הדגשה שלי י.ל.) חסימת הנוף המוחלטת עולה בבירור גם מנספחים מס' 11 ו-13 למוצג מספר 2 באסופת המסמכים שהגישו הנתבעים, בהם נראה בבירור כי כל קומת הקרקע במבנה הקדמי מוסתרת לחלוטין ע"י הקומה הנוספת וכי המרחק בין המבנים קטן ביותר. וראו גם עדות מר גרנות בעמ' 22 לפרוטוקול שורות 17-22.

עמדת ועדת הערר בסוגיה-

74. בערר שהגישו התובעים לוועדת הערר ביקשו הם לתקוף את החלטת הועדה המקומית שהתירה למבנה האחורי לבנות לגובה. ועדת הערר בהחלטתה מיום 17.11.1 התירה לנתבעים לבנות את הקומה הנוספת אך אסרה על בניית עליית הגג. החלטת ועדת הערר הראשונה שמצאה להתיר את בניית הקומה הנוספת ולאסור על בניית עליית הגג ניתנה מבלי שהועדה קיימה ביקור במקום.

75. רק בעקבות העתירה המנהלית על החלטת ועדת הערר, במסגרתה החזירה כב' השופטת וילנר לוועדת הערר את התיק לעיון מחדש בעניין עליית הגג, יצאה ועדת הערר לביקור במקום ולאחריו ניתנה על ידה ביום 24.10.12 החלטה נוספת בה היא קובעת לעניין הקומה הנוספת: **"לגבי עצם הפגיעה, לאחר שסיירנו במקום, השתכנענו כי אין מקום לשנות את החלטתנו הקודמת. יתר על כן, אילו היה הדבר בסמכותנו, סביר להניח שהיינו מבטלים לחלוטין את הקומה הנוספת שאושרה, לנוכח הפגיעה המאסיבית שזו יוצרת בדירות העוררים."** (הדגשה שלי י.ל.)

76. ועוד קובעת הועדה **"כאמור, הנושא של תוספת הבנייה בא לבחינתנו רק לעניין תוספת עליית הגג. אם היינו יוצאים לסיור במקום בטרם מתן ההחלטה הקודמת, ספק אם היה מקום לאשר גם את הקומה הנוספת, קל וחומר את עליית הגג, כפי שהוצעה."** (הדגשה שלי י.ל.) ענינו הרואות כי גם הוועדה המחוזית מצאה כי בשל הפגיעה הקשה בתובעים לא נכון לאשר את הקומה

הנוספת, אלא שידיה היו כבולות בעניין מהטעם שמה שהונח לפתחה באותו השלב היה רק מתן החלטה באשר לקומת עליית הגג.

עמדת כב' השופטת וילנר-

77. המסקנה כי הקומה הנוספת תחסום כליל את הנוף לדירות קומת הקרקע במבנה הקדמי מופיעה גם בפסק דינה של השופטת וילנר, סעיף 62 לעיל, אשר בשל חשיבות הנאמר בה מוצאת אני לחזור ולצטטה בשנית: **"אין ספק כי נוף זה יוסתר ממילא על ידי בניית הקומה הנוספת שאושרה על ידי ועדת הערר ואינה עוד לדין. על כן, ברי כי בניית עליית הגג לא תשפיע על מידת הסתר הנוף הנשקף מהדירות המצויות בקומה זו"**.

78. לא מצאתי לנחוץ לבחון האם קיימות חלופות תכנוניות אחרות אשר יאפשרו חיזוק המבנה האחורי שכן קיומן או העדרן לא יהיה בהן כדי להעלות או להוריד שעה שמצאתי כי הוספת הקומה הנוספת תגרום לפגיעה מהותית ובלתי מידתית אשר די בה כדי למנוע את הבניה. ממילא גם כל פתרון חלופי כפוף לאישור של מוסדות התכנון ולא הוצגו לפני אישורים כנ"ל לגבי חלופות בניה נטענות.

79. מהמקובץ לעיל, מוצאת אני לקבוע כי בניית הקומה הנוספת תגרום לפגיעה של ממש בזכויותיהם של מקצת דירות התובעים. לאור זאת אין להחיל על הבית הנדון את הוראות סעיף 11 לחוק החיזוק, וכפועל יוצא מכך לא עומד לנתבעים הרוב הדרוש לפי חוק החיזוק המאפשר להם בניה בהתאם לתוכנית הבנייה נושא ההליך.

80. עם זאת, מלאכתי לא תהיה שלמה אם לא אמליץ לפני הנתבעים שלא לזנוח את כוונתם לחזק את המבנה שבבעלותם מפני רעידות אדמה, להירתם להגשמת צורך חשוב זה ולבחון אפשרויות בנייה חלופיות. לאחר שהנתבעים הביעו דעתם במסגרת ההליך כי יסכימו לתוכניות בנייה אשר לא יבנו לגובה מוצע לנתבעים לשקול מחדש את התוכנית הראשונית אשר נזנחה בעקבות התנגדות התובעים. ולעניין זה אפנה לדבריו המלומדים של כב' השופט יצחק כהן בפסק דינו בע"א (חי') 899-03-09 **שרה קלצוק נ' צבי אורן** (פורסם בנבו), אשר אותם יש להחיל על בית זה בן שני המבנים בשינויים המחויבים. תקוותי היא כי יהיה בהם כדי להפיג את חששם של הנתבעים מפני התנגדויות עתידיות לתכנית חדשה ככל שייזמו:

"אם יפעל היזם בשיווי בין בעלי הדירות בבית, ויפעל בתום לב, ויחשב את חישוביו לפי הנוסחאות הקבועות הסעיף 5 ל"חוק החיזוק", זכויות הקניין של המיעוט לא תוכלנה לגבור על הזכויות הקנייניות של הרוב, ולמפקח על רישום מקרקעין לא תהיה עילה לדחות בקשתו של הרוב לכפות על המיעוט את ביצוע עבודות החיזוק ובניית הדירות הנוספות לשם מימון עבודות החיזוק, חרף הפגיעה הנגרמת לזכותו הקניינית של המיעוט."

81. לאור האמור ניתן בזאת צו מניעה קבוע האוסר על הנתבעים לבנות בהתאם לתכנית הבניה נושא ההליך.

82. אני מחייבת את הנתבעים, ביחד ולחוד, בהוצאות התובעים, לרבות שכ"ט עו"ד, בסך של 8,000 ₪. סכום שלא ישולם בתוך 30 יום יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (11.2.14) ועד התשלום המלא בפועל.

ניתן בהעדר הצדדים ביום יב' בחשון התשע"ד (5.11.14)

העתיקים ישלחו לצדדים.

יעל ליבוביץ

מפקחת על רישום מקרקעין